

daba desamparado. Para evitar esto el pretor dispuso que se considerase como no hecha la adopción, pero ésta solución resultaba insuficiente en el caso de que hubiera muerto el padre natural. Justiniano estableció una distinción entre la adopción plena y la menos plena, en ésta última el adoptado seguía bajo la potestad de su padre natural. Una vez que se eliminó la diferencia entre la agnación y la cognación, siempre el adoptado tuvo derecho a heredar al padre natural.

- 4) La legitimación. Subsiguiente matrimonio. Oblación de la curia. Rescripto imperial

La legitimación fue una forma jurídica de adquirir la patria potestad sobre los descendientes nacidos fuera del matrimonio.

Respecto de las uniones de hecho como el concubinato, para el derecho se suponía que no tenían madre ni padre, incluso no se les reconocía el derecho de alimentos.

La legitimación propiamente aparece en tiempos del Constantino, en que se aplicó a los hijos que nacían como producto del concubinato. Constantino tuvo como objetivo disminuir el concubinato, entonces se permitió que se pudiesen legitimar por subsiguiente matrimonio los hijos que hubiera tenido el pater con la concubina siempre que fuera una mujer ingenua.

- 5) La legitimación estaba a cargo del pater ya que era el fundador de la familia y era el que ejercía la patria potestad. Se podían legitimar a los hijos naturales y a sus descendientes legítimos, pero no a los ilegítimos debido a que éstos debían ser legitimados por su respectivo padre por aplicación del principio de que a nadie se le podía dar en contra de su voluntad un heredero forzoso.

Formas de legitimación

- 1) Legitimación por subsiguiente matrimonio; Antes de Justiniano requería dos condiciones:

- 2) Que no existieran hijos legítimos de anterior matrimonio, para evitar que éstos resultasen perjudicados por la legitimación, ya que los legitimados tenían derecho a una parte de la herencia.
- 3) Que la madre de los hijos a legitimar fueran de una ingenua.

Justiniano apaciguó éstas exigencias, con respecto a la primera se eliminó como tal, y con relación a la segunda era suficiente con que la mujer fuera libre.

Pero estableció las siguientes condiciones:

- 1) Se tenía que tratar de un matrimonio que no estuviese prohibido según las leyes en el momento de la concepción o del parto.
- 2) No se podían legitimarlos hijos de cristiano o judía o viceversa.
- 3) Tampoco los de ciudadanos y extranjeras adúlteros, incestuosos, etc.
- 4) Se tenían que otorgar instrumentos nupciales, con el fin de que la celebración del matrimonio quedase acreditada.
- 5) No era necesario que los instrumentos fueran dotales debido a que en muchos casos se contraían justas nupcias con mujeres pobres y si se requería ésta clase de documentación quedarían excluidos los hijos naturales de la posterior legitimación por subsiguiente matrimonio con la concubina.
- 6) La persona sobre la que recaía la legitimación debía dar su consentimiento, porque iba a sufrir una capitis deminutio mínima ya que pasaba de ser un sui iuris a un alieni iuris. Era suficiente con no oponerse a la legitimación.

- a) Evolución histórica de la legitimación por oblación de la curia
Hubo un momento en que el cargo de curial fue una carga pesada que todos rechazaban porque tenían que cobrar las contribuciones, los emperadores lo declararon hereditario, pero no podían

heredar el cargo de curial los hijos naturales, entonces Teodosio II y Valentiniano III, para aumentar las curias permitieron que el padre fuese o no curial, pudiera incluir a sus hijos naturales en matrimonio a individuos de la misma corporación, se los autorizaba para dejar a unas y otras hasta la totalidad de sus bienes por donación o testamento.

Más tarde se les dio a los hijos naturales inscriptos en la curia la condición de herederos ab intestato de sus padres suponiendo que esa sería la voluntad de éstos.

También estableció Justiniano que los hijos naturales adscriptos a la curia tuvieran el carácter de legitimados, independientemente de que el padre tuviese hijos legítimos, se les permitió a los naturales adscribirse por sí mismos a la curia cuando el padre muriese si dejar descendencia legítima.

Antes de lo implementado por Justiniano se establecían los siguientes requisitos:

- 1) No tener ascendientes legítimos;
- 2) Que el padre le diese al hijo 25 arpentas (fanegas de tierra) ya que era indispensable tener tierras para desempeñar el cargo de curial.
- 3) Que los hijos que se fueran a adscribir lo consintieran.

b) Legitimación por rescripto imperial

Se daba cuando el emperador les concedía la gracia a los hijos naturales poder ser hijos legítimos.

Para el rescripto se tenían que dar las siguientes condiciones:

- 1) Debía solicitarlo el padre o los hijos, cuando el primero hubiese manifestado esa voluntad.
- 2) No tenía que haber hijos legítimos para que éstos no fueran perjudicados.
- 3) Se tenía que acreditar que no era posible el subsiguiente matrimonio, por ejemplo por haber fallecido la madre, por encontrarse ésta ausente, o si se hubiera casado posteriormente con otro.

Ésta fue una de las formas de legitimar sobre todo en tiempos en los que Justiniano había prohibido la adrogación.

c) Efectos de la legitimación

- 1) Las tres formas de legitimación vistas hacían adquirir la patria potestad sobre el legitimado, que, de ser sui iuris pasaba a ser alieni iuris.
- 2) Por subsiguiente matrimonio el legitimado quedaba equiparado al filius nacido dentro de las justas nupcias, adquiriendo los derechos de agnación con los agnados de su pater.
- 3) Por la oblación de la curia: también el hijo adquiría la calidad de legítimo, podía recibir la totalidad del patrimonio del pater o el equivalente que le correspondía al hijo menos favorecido si el pater tenía descendientes legítimos, pero no entraba en la familia, solo adquiría derechos con respecto al pater no con respecto a sus agnados.
- 4) En la legitimación por rescripto, los legitimados adquirirían derechos con respecto al padre y a los agnados de éste, que hubiesen consentido en la legitimación, permaneciendo extraños con respecto a los demás.

B) Exclusión de los filii

1) Etapas de la emancipación:

Fueron dos:

- a) En la época antigua el pater lo imponía como pena a los hijos, expulsándolos de la casa por medio de la mancipatio unida a la vindicta, quedando en calidad de libertos y produciéndose un rebajamiento a su persona ya que perdían la ingenuidad, la gentilidad, los derechos de agnación, tutela y sucesión además de todos los derechos políticos los que antiguamente iban unidos a la gentilidad.

Con el paso del tiempo los derechos políticos dejaron de estar asociados a la ingenuidad, se vio a la emancipación como un beneficio para el hijo, se rompía con el vínculo de la patria potestad y éste

se transformaba en un *sui iuris*. En tiempos del derecho clásico y en tiempos de Constantino se equiparó la emancipación a la manumisión, y se estableció que podía revocarse si el hijo era ingrato para con el emancipante.

2) Formas de realizarla

El acto de la emancipación se hacía de tres maneras diferentes:

- a) Emancipatio antigua
- b) Emancipatio anastasiana
- c) Emancipatio Justiniana

- a) Emancipatio antigua: Al principio a la patria potestad se la consideró perpetua, por eso en los tiempos antiguos no había una forma para emancipar a los descendientes, sin embargo ante determinadas dificultades que le pudiera generar un *filius* se amparaba en la disposiciones de la ley de las XII Tablas por la cual se establecía que, si un *pater* emancipaba tres veces a un hijo lo sacaba definitivamente de su potestad, se lo consideraba *in mancipium*: al hijo se lo podía vender tres veces, a la hija una vez a una persona de confianza llamada *pater fiduciario* que lo manumitía dos veces para que volviera bajo la potestad del *pater*, pero a la tercera vez lo vendía sin manumitirlo. Después de ésta venta el *pater* lo tenía *in mancipium* no bajo la patria potestas, entonces lo manumitía por la vindicta, quedando respecto del descendiente manumitido como *patrono* teniendo los derechos de tutela y sucesión. Se añadía a la tercera venta un pacto de fiducia por el cual el comprador se obligaba a vender de nuevo el hijo al padre sin manumitirlo.
- b) Emancipación Anastasiana: Anastasio dispuso en el año 531 a.C. que el *pater* pudiese emancipar a los hijos obteniendo un *rescripto* imperial que le diera la emancipación, ésta se aplicaba los *ausentes* e *infantes*.

- c) Emancipación Justiniana: Justiniano en el año 531 a.C. estableció que el pater podía emancipar utilizando el procedimiento de la emancipación anastasia o con una simple declaración ante el magistrado. Comparecían ante éste el pater y el filius; el pater manifestaba su voluntad el hijo no lo contradecía y el magistrado aprobaba la emancipación de la cual se levantaba el acta correspondiente, la se guardaba en el registro.

A través de las formas ya descriptas el pater podía emancipar al descendiente de cualquier grado, que estuviese bajo su potestad, podía emancipar al nieto y retener al hijo, o emancipar al hijo y retener al nieto, o emancipar a los dos a la vez.

4) Efectos

El ascendiente perdía el poder paterno sobre el emancipado y no lo adquiría sobre los hijos que éste tuviese de allí en adelante.

- a) El descendiente dejaba de estar sometido al poder paterno, haciéndose sui iuris, con plena capacidad jurídica.
- b) En el derecho antiguo como el emancipado salía de la familia civil rompiendo la agnación, se perdían los derechos de sucesión y tutela.
- c) Si el emancipado tenía hijos, todos los que fueran concebidos después de la emancipación caían bajo su potestad.
- d) En cuanto al patrimonio, el emancipado al hacerse sui iuris contaba con capacidad jurídica plena. Los peculios le seguían perteneciendo en propiedad el castrense y quasi castrense; en cuanto al profecticio se estableció que éste conservaba la administración, adquiría la propiedad si el pater emancipante no se la quitaba expresamente; el adventicio seguía perteneciendo al emancipado, administrando y usufructuando al mismo, al principio el pater se reservaba la tercera parte en propiedad y luego Justiniano dispuso que usufructúe la mitad.

III. La Patria Potestas y las Manus

A) El rol desempeñado por el Pater Familiae

Como *sui iuris*, tenía a todas las persona libres bajo su potestas. La familia o Domus fue originariamente un grupo de personas sobre las cuales el pater familias ejercía su potestad y estaba compuesta por el éste, y las personas sometidas bajo su poder.

El poder del pater significaba el dictado de sentencias por las que podía condenar a los miembros de la familia a penas como la exclusión de la domus (hogar), la flagelación, la prisión y hasta la muerte.

La familia estaba compuesta por varios aspectos que la caracterizaban, uno de ellos era el patrimonio familiar común que se transmitía a través de las generaciones, pero el titular solo era el pater y cuidaba de la buena administración de los bienes.

1) Los poderes del Pater

- a) El conjunto de poderes que el *pater familias* ejercía sobre las personas libres que constituían la familia, se llamaba *patria potestas*. Ésta era privativa de los hombres, pero en casos excepcionales se admitió que las mujeres que fueran *sui iuris* pudieran ejercerlas y por una constitución de Diocleciano, pudieron adoptar a los hijos perdidos.
- b) La palabra *manus* había manifestado la existencia de un poder sobre el conjunto de la familia, hasta que con el paso del tiempo fue privativo solo de la potestad ejercida sobre la mujer casada llamada *uxor*.
- c) Tenía la *domenica potestas* o poder sobre los esclavos y;
- d) El *mancipium* o cuasi servidumbre de personas libres vendidas al *pater*.

2) Implicancias de la patria potestas:

Períodos:

- 1) En los tiempos más remotos el *pater* era jefe político, militar y religioso, su poder era absoluto, el fundamento se hallaba en el culto doméstico.
- 2) En el período clásico, con la decadencia del culto doméstico, y con el apoyo de las leyes los *fili* empiezan a tener cierta independencia desde el punto de vista jurídico.
- 3) Lo expuesto anteriormente se consolidó en tiempos de Justiniano.

Requisitos para tener la ejercer la patria *potestas*

- 1) Ser varón: debido a que la mujer tenía el culto doméstico de su marido, no podía presidirlo por no pertenecer a él por nacimiento, sino por las justas nupcias.
- 2) Ser ciudadano romano.
- 3) Ser *sui iuris*: En el caso de que su padre no lo fuera la ejercería su abuelo o ascendiente que estuviera con vida.

El ejercicio de la patria *potestas* antes de Justiniano

Comprendían los siguientes aspectos:

- a) Podía reconocer o rechazar (*execratio*) al hijo cuando nacía, si era rechazado quedaba fuera de la familia y era muerto o expuesto. Si lo reconocía quedaba bajo el poder paterno.
- b) El derecho de vida y muerte; denominado *ius vitae*, éste derecho era usado con asistencia del *concilium* doméstico, su intervención no era necesaria ni el *pater* tenía que seguir lo que éste resolviera. Desde los comienzos del Imperio éste derecho se fue restringiendo, Trajano estableció que quede libre del poder paterno el *filius* que hubiera sido tratado inhumanamente por su *pater*.
- c) El *ius exponendi* o derecho de exposición; el *pater* realizaba la exposición para que los hijos fuesen recogidos, obteniéndose en la medida de lo posible un buen precio en el mercado público.

- d) El *ius vendendi*; Se realizaba por la *mancipatio*, el *pater* se reservaba la facultad de readquirirlos. El que era vendido quedaba *in mancipium* del comprador, en caso de que lo liberaba volvía bajo la potestad del *pater*. La Ley de las XII Tablas estableció que fuera liberado en el caso de que el *pater* lo vendiera tres veces, la jurisprudencia interpretó que la ley podía estarse refiriendo a los descendientes que no fueran hijos (hijas, nietos, etc.) era suficiente con una sola *mancipatio* para que el *pater* perdiese la potestad sobre los *filius*, con el paso del tiempo se usó como medio para mancipar a los sometidos a ese poder.
- e) El *ius noxae dandi* o entregarlos *in noxa*; se hacía con el fin de que el *pater* no respondiera por los actos realizados por aquellos que estaban bajo su *potestas*, en los casos en que ocasionaban daños a terceros el *pater* los entregaba a éstos con el fin de que trabajasen durante un tiempo y así indemnizaren a la víctima. También estaba la posibilidad de pagar voluntariamente el daño causado.
- f) Derecho a oponerse a que los filis contraigan matrimonio, negando su consentimiento de manera justificada;
- g) Todo lo adquirido por los *liberi* pasaba al patrimonio del *pater*, hasta que aparecieron las restricciones al poder del *pater* en la administración patrimonial con los peculios.
- h) Tenía facultades para corregirlos y educarlos.
- i) Fijar el domicilio de los mismos.
- j) Hacer testamentos para ellos cuando fueren furiosos o impúberes.
- k) Designarles por testamento un tutor, para que en caso de muerte del *pater*, el tutor supliese la incapacidad de los *fili*.
- l) El *filius* gozaba del *ius connubium* y podía ejercerlo con permiso del *pater*.
- m) También tenía el *commercium* pero todo lo adquirido era para el *pater*. Hasta que aparecieron a fines de la República los peculios.

- n) Donación hecha por el *pater*: Eran las realizadas a las personas sometidas a su patria potestad. Los principios del Derecho romano impedían esta clase de donaciones, porque la unidad del matrimonio hacía imposible esta clase de liberalidades. Para dar validez a los actos de esta naturaleza era preciso un legado *per praescriptionem*. En la época de Diocleciano se dictó una nueva regla en virtud de la cual, si el padre donante moría sin haber revocado la liberalidad, ésta era válida, salvo reducción, si afectaba a la cuarta Falcidia.

2) Extinción de la patria potestad

Podía ocurrir de otras maneras denominadas “necesarias” que eran:

- a) La muerte del *pater familias*.
- b) Podía ocurrir de manera voluntaria y solemne en la emancipación.
- c) La *capitis deminutio* tanto del *pater* como del *filius*, ya que le vedaba la capacidad jurídica. En el caso de la pérdida de la libertas y si el cautivo regresaba a Roma por aplicación del derecho del *postliminium* a la patria potestas se la consideraba en suspenso, hasta dicho regreso o hasta la muerte. Durante ese período que el *pater* no estaba los *fili* se transformaban en *sui iuris*. En el caso de una *capitis deminutio* media que podía sufrir por una deportación, recobraba la patria potestad cuando el emperador le devolvía, por un rescripto, los derechos que había perdido, empleando la fórmula *restitutio te per omni*, o le reintegraba especialmente el ejercicio de la patria potestad. En el caso de la *capitis deminutio* mínima, que ocurría en el caso de una *adoptio*, cesaba la patria potestad para el *pater*, uno de los efectos de la *adoptio* plena pero no de la *minus* plena.

Por disposición de la ley

- a) Había casos en los que se imponía al *pater* como una pérdida la patria *potestas*, por ejemplo cuando celebraba un matrimonio incestuoso o exponía a los infantes.
- b) Los casos en los que se autorizaba al hijo a pedir la liberación, por ejemplo cuando el padre maltrataba al hijo o prostituía a la hija.
- c) Se declaraba extinguida la patria potestad por indignidad obtenida por el hijo.

En tiempos de la República se estableció la idea de que, la potestad del pater debía tener un control del Estado, fue que se le impuso a los censores el contralor del poder ejercido por el pater, para que éste no lo ejerciera arbitrariamente, éste aspecto influyó en la modificación de la participación de todos sus miembros.

Ésta atenuación de los poderes significó poner límites a la potestad de vida y muerte, a partir de entonces tal aspecto quedaba también a consideración de una junta consultiva de parientes. Con Justiniano y la Influencia del Cristianismo, la patria potestad quedó limitada a ser un poder disciplinario y de corrección.

El nacimiento

En Roma el nacimiento de un niño era un acontecimiento de importancia, que estaba rodeado de un ritual religioso; el mismo era prerrogativa de las mujeres mayores, el niño era criado por su madre o por una nodriza.

El Final de la vida

Producida la muerte de un romano su cuerpo era embalsamado provisoriamente, las mujeres rodeaban al difunto para llorarlo, y durante los días de luto olvidaban completamente lavarse y peinarse.

La Vestimenta de la mujer

Las mujeres debían llevar toga igual que los hombres la de éstos era más larga. Las mujeres usaban la stola, su parte inferior era de color púrpura impuesto por el senado para que las matronas se diferenciaron de otras mujeres de bajo status social, por ejemplo las esclavas. Esta vestimenta podía ser cubierta por una toga rectangular que cubría todo el cuerpo, las puntas quedaban libres para cubrirse la cabeza.

El Parentesco

En Roma existió un parentesco civil o agnación y uno natural o cognación. También la legislación romana reconoció un tercer vínculo parental, la afinidad que se formaba entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge.

La Agnación

La agnación es el parentesco civil reconocido por el derecho romano que unía a todas las personas que se encontraban sometidas a la patria potestad o a la potestad marital (manus) de un jefe de familia. La agnación quedaba suspendida en relación a la mujer, que era cabeza y fin de su propia familia. La mujer fue la representante de la familia cognaticia. Integraban la familia en calidad de agnados todas aquellas personas sometidas a la potestad de un eventual pater para el supuesto de que éste viviera; se constituía además entre la mujer casada cum manu y el pater, que ocupaba el lugar de hija (loco filiae).

La Cognación

La cognación era el vínculo de parentesco fundado en el vínculo de sangre que unía a las personas que descendían unas de otras de un antepasado común, que podía darse tanto por la línea femenina como por la masculina. La mujer casada in manu era agnada con relación a la familia del pater bajo cuya potestad se encontraba y cognada respecto de los miembros de su familia anterior.

La afinidad

La afinidad es el vínculo que nacía entre los cónyuges por el matrimonio y el que existía entre uno de ellos y los parientes consanguíneos del otro, las fuentes nos dicen que los afines son los cognados del marido y de la mujer llamados así porque en las nupcias se unen dos cognaciones que son diversas entre sí.

Concepto y evolución histórica de los peculios. Condición del filius. Capacidad de éste. El peculio profecticio, castrense, quasi castrense y los bona adventicia

- a) Concepto: Era una parte del patrimonio que el filius o el esclavo recibían de su pater, con el fin de que al administrarlo respondieran con él por las obligaciones contraídas para que se eximiera así, de responsabilidad al pater familias.
- b) Capacidad: Como hemos visto el filius tenía capacidad de hecho pero su capacidad jurídica era muy incompleta, de modo que era suplida por el pater familias quien tenía plena capacidad jurídica, pero con la asignación de los peculios la situación se fue modificando, ya que toda la responsabilidad no caía sobre la cabeza del pater.
- c) Las consecuencias que se derivan de la plena capacidad jurídica del pater eran:
 - 1) El pater tenía el derecho de propiedad sobre todo el patrimonio, al principio, luego, con la aparición de los peculios, el hijo se volvía administrador de esa porción patrimonial en provecho propio respondiendo también a los acreedores, servía para eximir al pater de que los acreedores fueran contra él.
 - 2) Debido a la falta de capacidad jurídica no podía constituirse el filius en acreedor o deudor del pater, ni éste lo será del filius. Además cuando el pater muriera el filius al ser su heredero continuaría la personalidad jurídica del de cuius (fallecido) no pudiendo ser nadie deudor o acreedor de sí mismo.

- 3) Podía contratar el padre en representación del filius, o éste para el pater.
- 4) Con el paso del tiempo aparecieron los peculios. Se trataba de un patrimonio chico, de menor entidad que tenía el filius en relación al que le pertenecía al pater, y estaba separado del patrimonio del pater, luego se dio en beneficio de los esclavos.

Su nombre proviene de pecus (ganado) y se relaciona con su origen porque cuando empezó a darse en la mayoría de los casos era ganado, ya que en su mayoría se dedicaban a la agricultura y a la ganadería por eso era lo que el pater les daba. Había una diferencia entre el peculio de filius y el del esclavo: al primero se le daba la administración de los bienes y en algunos casos podía ser propietario de esa porción patrimonial. En el caso de los esclavos solo tenían la administración.

d) Clases de peculios

- 1) Peculio profecticio: Era aquél cuyos bienes procedían del pater, quedaba a criterio de éste una vez que lo constituía dejarlo sin efecto. Los bienes que lo integraban continuaban siendo de propiedad del pater, el filius tenía la administración, pero estaba restringido en la realización de ciertos actos: por ejemplo no podía hacer manumisiones, ni ejecutar actos jurídicos sin permiso del pater, los contratos que celebrase, mientras obligaban al hijo in solidum, el pater respondía hasta el monto del peculio; éste podía ser deudor o acreedor del filius hasta el monto del peculio. Cuando el pater fallecía el peculio se repartía entre todos los hijos al igual que el resto del patrimonio del pater, los acreedores podían accionar en contra del patrimonio como de los bienes que habían integrado el peculio.

Una constitución del emperador Claudio dispuso que esta clase de peculio se consideraba separados del patrimonio del pater cuando éste fue confiscado por el Estado; los hijos podían adquirirlos en propiedad cuando el patrimonio era enajenado y no los quitaran expresamente.

- 2) Peculio castrense: Se creó en tiempos de Augusto, sostenido por los emperadores posteriores con el fin de ganarse la aprobación del ejército y mantenerse en el poder. Era todo lo que el hijo de familia adquiría como soldado u obtenía por esa calidad, comprendía:
- a) Las donaciones que le hacía el pater cuando ingresaba al ejército, también lo donado por la madre, parientes y amigos.
 - b) Los bienes recibidos inter vivos de la mujer para sostener los gastos de la milicia.
 - c) Todo lo donado por cualquier persona en virtud de su función militar.
 - d) La herencia de un compañero de armas, siempre que le dejasen la herencia cuando fuese militar.
 - e) Todo lo adquirido con el peculio castrense.
 - f) El Senadoconsulto Macedoniano dispuso que el filius fuese considerado con respecto a éste peculio como sui iuris y pater familias, ello traía como consecuencia que tenía la propiedad del mismo pudiendo disponer de los bienes a título oneroso o gratuito.
 - g) Efectos jurídicos del peculio profecticio:
 - Si el hijo sufría la pena de deportación esos bienes no eran apropiados por el pater sino pasaban bajo el poder de éste.
 - El pater podía tomar las herencias que el hijo no aceptaba.

3) Peculio quasi castrense

Se implementó en tiempos de Constantino, al principio estaban constituidos por los bienes adquiridos por los filii en virtud de ciertos cargos que desempeñaban en la Corte, luego se equipararon a los militares aquellos que desempeñaban ciertos oficios en el palacio imperial.

Teodosio el Joven dio éste beneficio a los letrados, León y Autenio lo dieron a los obispos, presbíteros y diáconos; Justiniano a los médicos del Príncipe, los profesores de artes liberales y a todos los que recibieron liberalidades del emperador o de la emperatriz o percibiesen retribución del Estado.

Los derechos del filius sobre éste peculio son los mismos que los del peculio castrense, pero hasta tiempos del Emperador Justiniano el derecho de disponer de éste peculio por testamento, solo pertenecía a los que lo hubiesen obtenido por una concesión expresa.

4) Peculio adventicio

El Emperador Constantino declaró que era propiedad de los hijos el patrimonio de lo heredado por testamento o ab intestato de parte de la madre, con la reserva al pater mientras viviese de la administración y usufructo al padre, que no estaba obligado a dar fianza, ni a rendir cuentas; pero nopodía enajenarlos sin el consentimiento del hijo, salvo cuando fuera por no poder conservarlos o para pagar deudas.

En caso de emancipación el pater retenía un tercio del peculio adventicio convirtiéndose en propietario de esa parte, con el paso del tiempo Justiniano estableció que el pater tenía la mitad en usufructo, cuando fallecía el padre el hijo adquiría la propiedad de éste.

La regla era que el hijo tenía la propiedad del peculio adventicio aún bajo la potestad de su pater, en casos excepcionales se les daba además la libre administración, el usufructo y la libre disposición, por eso había un peculio extraordinario, para distinguirlo del general y ordinario.

- 5) El peculio extraordinario era respecto de los siguientes bienes:
 - a) Lo adquirido por el hijo en contra de la voluntad del padre.
 - b) Los que se le dejaban al filius bajo condición de que el pater no tuviese respecto de ellos la administración o usufructo.
 - c) La parte que le corresponde al hijo de la herencia del hermano a cuya sucesión concurre con el pater.
 - d) Cuando el pater en su mala administración patrimonial hacía una malversación.
 - e) Los que el hijo adquiría cuando el pater se divorciaba injustamente.

V. El matrimonio. Concepto. Normas que lo rigen. El divorcio.

A) El Matrimonio: Concepto

En las Institutas 1, 9, 1 se lo define de la siguiente manera: “Es la unión del varón y de la mujer que comprende el comercio indisoluble de la vida”; Para Modestino: “las nupcias son la unión del varón y de la hembra, comercio de toda la vida comunicación del derecho divino y humano” en D. 23, 2, 1.

Era común que el pater eligiera a la futura nuera, sin perjuicio, de que, como en cualquier acto jurídico las partes dieran su consentimiento libremente para que el mismo no fuera declarado nulo.

Ésta elección eran el resultado del poder ejercido desde los orígenes mismos de la familia romana.

B) Elementos requeridos

Era una situación de hecho fundada en la convivencia o cohabitación del hombre y de la mujer, cuyo comienzo no estaba marcado por formalidad alguna, a lo que debía agregarse la intención permanente y recíproca de transformarse en marido y mujer, llamado por los romanos *affectio maritalis*; por lo tanto en el matrimonio encontramos dos elementos uno objetivo y otro subjetivo o intencional conocido como *affectio maritalis* que debía ser continua duradera en el tiempo, por ello con la simple relación inicial no bastaba.

La ausencia de la mujer impedía el perfeccionamiento del matrimonio, porque si la *affectio maritalis* cesaba el matrimonio se extinguía.

C) Las Formas en que se contraía la manus sobre la uxor

Había distintas formas de celebrar el matrimonio, tres de ellas ponían a la mujer bajo el poder absoluto del marido (*in manu mariti*). En los últimos tiempos de la República éstas formas habían caído en

desuso, en cambio se aplicó una cuarta forma que daba a la mujer su independencia.

Las tres formas más antiguas de contraer matrimonio fueron:

1) La *Confarreatio* o sea, la celebración del mismo a través de ritos religiosos, los desposados se hacían solemnes interrogaciones y declaraciones ante diez testigos, ciudadanos romanos, asistidos del gran pontífice y ante el sacerdote de Júpiter o Flamen Dialis, a quien los interesados ofrecían un sacrificio en el que figuraba un pan de trigo. La mujer desde entonces era admitida en la comunidad familiar del pater, quedando bajo la potestad de éste. Éste rito fue cada vez menos practicado al desaparecer las diferencias entre patricios y plebeyos. El emperador Tiberio abolió los efectos civiles de la *confarreatio*. Por éste procedimiento la mujer quedaba indisolublemente unida a la familia del marido y de su culto y no podía ser separada más que por el rito contrario (*contrarius actus*) de la *diffarreatio*.

Para *Ulpianus* la *confarreatio*, era bastante complicada en su celebración; para ellos debían producirse tres actos sucesivos:

- a) la *traditio*: entrega de la mujer en la casa de su padre; la colocación del vestido de la novia comenzaba en la noche de la víspera; le habían dividido los cabellos con la punta de una lanza, de manera que se formaban seis trenzas que rodeaban la cabeza y se fijaban con pequeñas cintas de lana. Luego se le colocaba una túnica, al parecer de una sola pieza ceñida al talle por un cinturón atado con un nudo ritual, el “nudo de Hércules”. Durante la ceremonia la esposa tenía sobre la cabeza un velo anaranjado, el *flammeum*, esa noche la misma se despedía de sus juguetes infantiles y entregaba su lar.
- b) La *deductio in domum*: Al día siguiente por la mañana sus padres y los invitados se reunían en la casa de la esposa y en el *atrium* se celebraba un sacrificio: era inmolada una cerda, a veces una oveja, y se observaban sus entrañas para deducir los auspicios. Ante la víctima del sacrificio los esposos cambiaban su mutuo consentimiento y la esposa pronunciaba la

fórmula: “Ubi tu Gaius, ego Gaia”, después de lo cual los presentes aplaudían alegremente gritando feliciter, como buen augurio.

Después todos se sentaban a la mesa común y el banquete se prolongaba hasta la noche. Cuando aparecía la estrella vespertina, la primera que brilla en el cielo, llegaba el momento de conducir a la joven esposa a la casa del marido. Entonces la joven aparentaba tener miedo y se refugiaba en los brazos de su madre, de los cuales se dejaba arrebatar con facilidad, era el simulacro de rapto, pero antes de que el esposo llegara, había un cortejo que se dirigía a la casa del futuro marido precedido por la esposa y rodeado de un séquito que entonaba cánticos religiosos; llegaba al futuro hogar, se le presentaba el agua lustral y el fuego sagrado, símbolo religioso y se simulaba el rapto descripto.

- c) Luego se producía la *confarreatio* propiamente dicha, donde se ofrecía compartir el pan de cebada o torta de harina, se ofrecía la comida del *panis farreus* a Júpiter, a la vez que se recitaban fórmulas sagradas, que solo ese grupo familiar conocía, y jamás podía llegar al conocimiento de un extraño, ajeno a la familia en cuestión, como se dijo debía ocurrir el acontecimiento en presencia del flamen *Dialis* y por lo menos 10 testigos.

2) La *Coemptio* (adquisición ficticia de la mujer) va haciéndose infrecuente en la época de Cicerón, como consecuencia de la aversión que sienten las mujeres hacia el matrimonio *cum manu*. En la época clásica cayó en desuso y solo perdura como institución la *coemptio fiduciae causa*, aplicable para que la mujer pudiera testar válidamente o cambiar de tutor.

3) El *usus*, o sea, el matrimonio por cohabitación, cuando el matrimonio había sido celebrado sin las formalidades de la *confarreatio* o de la *coemptio*, se aplicaban las normas propias de la *usucapción*, y el marido adquiría la *manus* por el *usus*, es decir reteniendo a la

mujer en posesión durante un año, en ese lapso la mujer podía interrumpir la cohabitación, permaneciendo fuera de la casa por tres noches. Éste modo de contraer matrimonio no sobrevivió hacia fines de la República y habría sido el Emperador Augusto quién lo abolió completamente.

D) Los Esponsales

La palabra sponsales, proviene del latín sponsio, era un contrato verbal, solemne celebrado entre los ciudadanos romanos. Antes de celebrar las justas nupcias se realizaba una promesa entre los que iban a ser marido y mujer en el futuro o sus patres, a partir de esa promesa se transformaban en esposos.

En los primeros tiempos el incumplimiento de los sponsales daba lugar a la acción de daños y perjuicios que se traducían en el pago de una suma de dinero.

Los sponsales crearon un lazo de cuasi afinidad entre los parientes de los comprometidos que constituyó un impedimento matrimonial; se prohibió contraer otra promesa de matrimonio, antes de disolver la anterior, bajo pena de infamia; se autorizó al prometido a perseguir por una *actio iniuriarum* a quien ofendiera a su futura esposa y se consideró adúltera a la prometida que no cumplía con sus deberes de fidelidad.

E) Matrimonio cum manu

Desde el antiguo derecho de Roma las mujeres casadas solían formar parte de la familia del marido colocándose bajo su potestad y rompiendo el vínculo agnaticio con la familia de origen; se configuraba entonces una forma de matrimonio cum manu, según el cual la mujer (*uxor in manu*) se hacía filifamilias y quedaba sometida al poder del nuevo pater, ocupaba el lugar de hija (*loco filiae*) y el lugar de nieta (*loco nepotis*), todo ello dependía de la situación en que se encontrara el marido (en ligar de hijo o nieto).

Aunque la condición jurídica de la mujer se definía en la fórmula *loco filiae mariti est*, el poder que el marido ejercía sobre su mujer difería radicalmente del que tenía respecto de sus hijos. El marido no había poseído el *ius vitae necisque* (derecho de vida y de muerte) sobre la mujer, ni el derecho de venderla o darla en *noxae*; es cierto que cuando la mujer se encontraba sometida a la *patria potestas* o a la tutela legítima (*tutela mulierum*), una y otra quedaban absorbidas por la *manus*.

Con respecto a la capacidad patrimonial, la *uxor in manu* estaba en una situación similar a la del hijo en potestad. En consecuencia si era *sui iuris* todo su patrimonio se transmitía al *pater*. La *manus* no nacía automáticamente por la sola celebración del matrimonio, sino que requería un acto legal especial para que el marido adquiriera tal potestad.

F) El Matrimonio *sine manu*

Fueron un medio para que el *paterfamilias* se procurase los hijos pero sin incorporar a la mujer con la que los tenía. La decadencia de la *manus maritalis*, desaparecida absolutamente alrededor del s. III d.C. hace habitual la práctica del matrimonio *sine manu*, en el que al no tener el marido poder alguno sobre la mujer, ésta quedaba en la misma situación patrimonial y familiar que tenía antes de las nupcias, su marido no era su tutor legítimo, ni era usual nombrar al marido tutor de la mujer.

G) Presupuestos de validez del matrimonio

Se exigió para que el matrimonio fuera válido el cumplimiento de ciertos requisitos: capacidad jurídica o *ius connubius*, capacidad sexual para procrear o llegada a la pubertad a los doce la mujer y a los catorce el varón, consentimiento de los contrayentes, consentimiento de los *patres*, cuando los desposados fueran *alieni iuris*.

En el caso de la mujer el consentimiento no era requerido a su *pater*, porque los hijos que nacieran de la unión matrimonial no iban

a formar parte de su familia, sino de la del marido. El consentimiento podía ser negado por el *pater*, hasta que la *Lex Iulia* autorizó la venia supletoria del magistrado cuando la negativa no estuviera justificada. Para las mujeres *sui iuris*, menores de veinticinco años, el derecho imperial autorizó el consentimiento de la madre a falta del paterno, y hasta admitió subsidiariamente el de los próximos parientes.

H) Impedimentos para contraer matrimonio

Podían ser de dos clases absolutos o relativos:

- a) Relativos: Se excluía la posibilidad de que una persona pudiera contraer matrimonio con cualquier otra; en el segundo caso era cuando si bien una persona por algunos de los impedimentos consagrados no podía contraer matrimonio con una persona pero sí podía hacerlo con otra.
- b) Eran impedimentos absolutos los siguientes: la esclavitud, el matrimonio anterior; en tiempos del cristianismo: la recepción de órdenes mayores y haber hecho el voto solemne de castidad.

Los impedimentos relativos procedían del parentesco y del delito (motivos de orden moral), por razones sociales y la necesidad de proteger a personas débiles.

- a) Por el parentesco: En línea recta en todos los grados, y en línea colateral hasta el cuarto grado, su fundamento se hallaba en el repudio al incesto, por eso la ley lo prohibía expresamente, así tenemos:
 - 1) La cognación natural: Se prohibía el matrimonio en línea recta *usque ad infinitum*. En línea colateral hasta el cuarto grado comprendían: primos hermanos, y entre un hermano y los descendientes del otro hasta el infinito.
 - 2) Cognación civil derivada de la adopción: El impedimento estaba dado entre adoptante y adoptado y descendientes del adoptado *usque ad infinitum* en línea recta. En línea colateral solo entre hermano y hermana mientras dure el vínculo de *adoptio*.

- 3) Afinidad: Impedía el matrimonio en línea recta hasta el infinito, en línea colateral solo hasta el segundo grado. No se podía casar con la hijastra, ni con la nuera debido a que ambas estaban en el lugar de hijas, tampoco con la madrastras no con la suegra, porque están en lugar de madres, no con el cuñado o cuñada, tampoco entre el marido de una mujer y la hija nacida de ésta después del divorcio, por mencionar algunos ejemplos. Pero como los parientes de los cónyuges no son afines entre sí, podían casarse cualquiera que fuera el grado de parentesco que los uniera con ellos, y también con los hijos que uno de los cónyuges tuviera de un matrimonio anterior, se podían casar con los del otro.
- 4) Cuasi afinidad: Fundado en la honestidad se prohibió el matrimonio entre:
 - a) Entre el padre de la mujer y la *uxor* de éste y todos sus descendientes *usque adinfinitum*.
 - b) Entre la madre de la mujer y el marido de ésta y sus descendientes.
- 5) Parentesco espiritual: Con la influencia del cristianismo se prohibió el matrimonio entre el padrino con el bautizado.
- 6) Parentesco natural: Es el que procede del concubinato o *contubernium*.
- 7) Por razón del delito estaba prohibido el matrimonio entre el adúltero y su cómplice; también entre el raptor y la robada, el Derecho Canónico estableció que si la raptada daba su consentimiento y estaban cumplidos los requisitos para contraer matrimonio éste podía celebrarse.
- 8) Por razones sociales: Al principio se estableció la prohibición de que contrajeran justas nupcias patricias y plebeyas, establecidas en la *Lex* de las XII Tablas y abolidas por La *Lex Canuleia*; luego se prohibió entre ingenuos y libertos prohibición que fue abolida por la primera de las leyes matrimoniales de Augusto, se estableció la prohibición entre los

senadores y sus agnados hasta el tercer grado, para casarse con mujeres de profesión o conducta deshonrosa, prohibición que fue suspendida por Justiniano. También se prohibía el matrimonio entre judíos y cristianos; y la que tenían los magistrados y sus hijos con las mujeres que vivían en las jurisdicciones donde prestaban sus funciones.

- 9) Por razón de protección: Se refería a las personas débiles, por ejemplo entre tutor y curador con sus respectivos pupilos, para poder hacerlo tenía que haber finalizado el vínculo, la pupila debía tener como mínimo veintiséis años y haberse rendido cuentas de la administración patrimonial.

I) Otros efectos del matrimonio respecto de los cónyuges:

Principal consecuencia del matrimonio era el deber de fidelidad de los cónyuges, el derecho trató más severamente la infidelidad de la mujer que la del varón; y en éste sentido la mujer adúltera cometía un delito público que se castigaba severamente. La mujer debía habitar la casa del marido, que constituía su domicilio legal; estaba obligada a seguirlo siempre, al menos que él se hiciese reo de algún delito. La mujer adquiría el nombre y la dignidad de su cónyuge, los que conservaba aunque quedara viuda, mientras no pasara a segundas nupcias, el marido tenía que dar protección a su mujer y representarla en la justicia, un cónyuge no podía ejercer contra otro acción que aparejara pena infamante, al marido se le otorgó el ejercicio del *interdictum de uxore exhibenda et ducenda* para hacerlo valer contra cualquiera que se apoderara ilegítimamente de una mujer, aunque fuera el propio paterfamilias, la mujer debía honrar al marido y obedecer a éste o al *pater familias* en cuya potestad se encontrase, el marido tenía la obligación de mantener a su mujer, ambos cónyuges se debían fidelidad, ayuda y alimentos, tenían el derecho a heredarse. Para dejar el matrimonio al margen de todo interés pecuniario, se prohibió que los cónyuges pudieran hacerse mutuas donaciones y que la mujer

fuera fiadora de su marido, prohibición ésta última que consagró el senadoconsulto Veleyano.

El *pater* de manera prioritaria y la madre excepcionalmente, tenían el derecho de corregir y educar a sus hijos.

J) Efectos del matrimonio respecto de los hijos, la filiación:

- a) Concepto: Derivada de las legítimas nupcias, en la procreación se derivaban consecuencias jurídicas, de allí surge la filiación.
- b) Efectos: Le daba al hijo la calidad de legítimo, la mujer debía probar la paternidad si el marido la negaba, la acción que se otorgó para el reconocimiento del hijo se llamó *actio partu agnoscendo*. Sin embargo la mujer que se creía embarazada en el momento del divorcio, tenía obligación de acuerdo a un senadoconsulto *Plaucianum*, de la época de Vespasiano, a comunicárselo al marido dentro de los treinta días. Más tarde el edicto del pretor extendió ésta disposición al caso de disolución del matrimonio por muerte del marido, supuesto que había dar aviso del embarazo a las personas interesadas.

K) Disolución del matrimonio:

Se podía disolver por muerte de uno de los cónyuges, por pérdida de la capacidad patrimonial, por sobrevenir un impedimento y por una causa específica; el divorcio.

La muerte era el medio natural de extinguir el matrimonio; si uno de los cónyuges vivía largo tiempo sin tener noticias del otro, y en circunstancias que hicieran presumir su muerte, se consideraba disuelto el matrimonio.

También había disolución del vínculo conyugal por pérdida de la capacidad de los mismos, en los casos de *capitis deminutio* máxima o media.

El divorcio era la falta de *affectio maritalis* de uno de los cónyuges o de ambos, cuando faltaba por consiguiente se disolvía el vínculo y no podían ser considerados ya como marido y mujer. No le estaba permitido a la mujer, dado su estado de dependencia a la patria *potestas* o *manus*, divorciarse de su marido, obstáculo que fue superado en la época republicana.

L) Legislación Matrimonial de Augusto

1) Leyes Julia *et Papia Poppaea*

La primera de ellas se promulgó en el año 762 d. C. en tiempos de Augusto, con el claro objetivo de combatir el celibato y fomentar la natalidad. Completó las disposiciones de la Ley Julia de *Maritandi Ordinibus*, del año 736, cuyas disposiciones completó, por lo que se la cita precedida del nombre de ésta, siendo difícil establecer que disposiciones pertenecen a una y cuales a la otra.

En ella se dispuso que:

- a) Se prohibieron los matrimonios entre personas de clases o categorías diversas, entre senadores y libertos o mujeres de dudosa reputación.
- b) Se favorecieron los matrimonios de personas de iguales condición, se les dio determinados beneficios.
- c) Se establecieron penas para los solteros y casados sin hijos; determinándose:
 - 1) Los solteros de más de 25 años y menos de sesenta; y las solteras de más de 20 y menos de 50 eran incapaces para heredar, tanto por testamento como ab intestato, y lo mismo como herederos que como legatarios.
 - 2) Los hombres casados que no tuvieran por lo menos un hijo legítimo y las mujeres casadas que no contasen con tres si eran ingenuas o cuatro si eran libertas, los viudos y divorciados que no se hubiesen vuelto a casar aunque tuviesen hijos solo podían recibir la mitad de lo que se les dejase o les tocara.

- 3) Aquellos que no tuviesen hijos vivos de su matrimonio no podían recibir uno del otro sino una décima parte del capital, cuya cantidad se podía ampliar a otro décimo por cada hijo difunto o nacido de matrimonio anterior.

Esta clase de incapacidades cesaban:

- 1) Por ponerse en regla dentro de los cien días siguientes a la delación de la sucesión.
- 2) Por tener la *solidis capacitas*, o sea, por tratarse de cognados hasta el sexto grado; de hijos de sobrinos hermanos hasta el séptimo, de próximos allegados y militares.
- 3) Por dispensa o privilegio particular, total o parcial, que primero se concedía por el Senado y después por el Emperador.

Para quienes cumplían con las disposiciones de Augusto, se consagraron algunos privilegios: ocupar un cargo público, el pago de ciertos tributos a quién tuviera tres hijos en Roma, y cuatro en el resto de la península Itálica; se eximía de tutela perpetua a la mujer que gozara del *ius liberorum*, ó sea la ingenua con tres hijos y la liberta con cuatro hijos.

M) Segundas Nupcias

La disolución del matrimonio por cualquier causa no impedía a los ex cónyuges pasar a segundas nupcias, solo que la mujer debía guardar luto por un período de diez meses, y de un año en el derecho post clásico.

Sin embargo se miró con poca estima al cónyuge bínubo, especialmente a la mujer. Los emperadores volvieron a la antigua tradición romana. Así Alejandro Severo prohibió a la viuda que contraía nuevas nupcias a educar a sus hijos.

N) El Concubinato

Existía una unión estable del hombre y de la mujer sin que medie intención recíproca de estar unidos en matrimonio. La mujer no

gozaba del rango de mujer casada, le faltaba el honor *matrimonii*; los hijos no entraban bajo la potestad ni a la familia del padre; seguían la condición personal de la madre.

El concubinato fue la única unión posible de libertos y mujeres sancionados con la tacha de infamia. No se lo miraba como a una unión inmoral o contraria a las buenas costumbres. Con el advenimiento del cristianismo se produce una reacción contra ésta clase de uniones.

Justiniano lo asemejó al matrimonio, aunque tenía rango inferior; dispuso que el concubinato no fiera admitido entre mujeres ingenuas y respetables, prohibiendo además que un hombre soltero tuviera varias mujeres concubinas, la mujer debía tener al igual que para contraer matrimonio la edad mínima de doce años, y la concubina de un hombre no podía serlo de su hijo o de su nieto; reputándose su infidelidad como adulterio, al igual que en la mujer casada.

O) Régimen Patrimonial de matrimonio

Quando por el matrimonio el marido adquiría la potestad marital sobre su mujer, todos los bienes que ésta poseía, si era *sui iuris*, pasaban a aquél, del mismo modo que las adquisiciones que realizara se convertían en propiedad del cónyuge, porque la mujer sometida a la *manus maritalis*, era patrimonialmente incapaz. A la muerte de su marido la sucedía como si fuera hija, y los derechos sucesorios en su familia de origen se extinguían al ingresar en la de su cónyuge.

En el matrimonio libre la mujer seguía perteneciendo a su familia de origen, o paterna, había en tal caso una separación de bienes. Si era *alieni iuris*, las adquisiciones realizadas durante el matrimonio se hacían propiedad de su paterfamilias y si tenía la calidad de *sui iuris* era propietaria de todos los bienes y de los que adquiriera durante las nupcias, con amplio poder de disposición. Sin embargo a fines de la República de acuerdo a reglas del jurisconsulto Quinto Muscio Scaevola, todas las adquisiciones de la mujer durante el matrimonio se presumían hechas por el marido, salvo prueba en contrario.

El marido no tenía facultad sobre los bienes propios de la mujer; y si ésta le encargaba la administración éste actuaba en carácter de mandatario. Éstos bienes destinados a la administración marital se llamaban extra dotales o parafernales. En cuanto a los bienes parafernales, el marido debía de actuar en todo de acuerdo con las instrucciones de la mujer, quedando el primero responsable por la pérdida que pudiera acaecer, si hacía un uso no autorizado de ellos. Disuelta las nupcias, el marido estaba obligado a restituir los bienes extra dotales, disponiendo la mujer en ese caso la *actio ad exhibendum*, como medida preparatoria de la *reivindicatio*. Los podía reclamar también por una *condictio*.

En el matrimonio sine manu, al existir un régimen de separación de los bienes conyugales, esto no se debía alimentos.

Estos principios generales relativos al derecho matrimonial de bienes se modificaron con la institución de la dote, que constituyó la columna vertebral del sistema patrimonial del matrimonio romano.

P) El divorcio: causas y efectos jurídicos. Repudio

Concepto: El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial.

1) Clases: El divorcio podía ocurrir por:

A) Por la muerte de ambos cónyuges o solo uno de ellos.

B) Por *capitis deminutio*, haciéndose las siguientes distinciones:

1) *Capitis deminutio* máxima: El matrimonio quedaba disuelto ipso facto, ya que la esclavitud quedaba equiparado a la muerte, en cuanto a sus efectos. El *Postuliminius* restituía los efectos del matrimonio *cum manus*, pero no libre, cuando los dos cónyuges caían prisioneros al mismo tiempo permanecían en cautividad el mismo plazo y volvían a la ciudad al mismo tiempo, se establecía que el matrimonio no había dejado de existir, ni se había interrumpido la cohabitación física ni el consentimiento. Justiniano dispuso que el matrimonio continuase subsistente durante cinco años, si el cónyuge

que no había caído en cautiverio contrajere nuevas nupcias antes de ese lapso se consideraba que había incurrido en la causal de divorcio injusto.

- 2) *Capitis deminutio* media: En los primeros tiempos producía la disolución del vínculo, porque el que la sufría quedaba equiparado al esclavo desde el punto de vista jurídico y ya no tenía el *ius connubium*, con el paso del tiempo solo producía el cambio del matrimonio justo al matrimonio *iuris gentium*. En tiempos de Justiniano como la ciudadanía perdió importancia no quedaba disuelto el vínculo matrimonial, salvo que el delito que la produjese cambiase el afecto de la mujer y ésta se casase.
 - 3) *Capitis deminutio* mínima: Solo disolvía el vínculo en el caso de que la misma produjera específicamente un impedimento, por ejemplo que un hombre se transformase en senador, en la época en que estaban prohibidos los matrimonios entre éstos y las mujeres de conducta deshonrosa. En tiempos de Justiniano solo tenía lugar en el caso de que un *pater* adoptase como hija a la mujer de su hijo, entonces los cónyuges resultaban hermanos y el vínculo incestuoso, esto se evitaba cuando el *pater* emancipaba previamente al hijo.
- C) En el divorcio se distinguen dos casos:
- 1) Divorcio por mutuo consentimiento: Se podía disolver el vínculo sin sanción o penalidad alguna cuando alguno de los cónyuges hacía votos de castidad; por impotencia del marido, por haber transcurridos tres años sin tener vida marital. Si no era por una de éstas causas, los divorciados debían permanecer toda su vida en un convento, sucediéndoles sus hijos en sus bienes; en defecto de los hijos los ascendientes y a falta de éstos, el convento.
 - 2) Divorcio por disenso de un solo cónyuge: Podía ser con o sin causa legítima:

- a) Sin causa legítima o sea por repudio: El que lo provocaba era recluido en un convento, perdiendo la dote o la donación *propter nuptias*, si no había ni una ni otra, la cuarta parte de sus bienes a favor del cónyuge inocente.
- b) Por causa legítima: El que lo provocaba o pedía no era castigado, pero las penas mencionadas recaía sobre el que hubiere dado motivo para el divorcio; por ejemplo, cuando la mujer concurría a baños o convites contra la voluntad del marido y si tomaba partes en espectáculos públicos contra la voluntad de éste o si cometía adulterio. Por parte de la mujer, cuando el marido la inducía al adulterio o atentaba a su castidad; cuando en menosprecio de su mujer tenía concubina en su casa, cuando la acusaba falsamente de adulterio y por impotencia probada durante tres años consecutivos.

3) Forma del divorcio

Antiguamente si el matrimonio era *cummanus*, solo se podía disolver por la *diffarreatio*, en el caso de una *coemptio* por una *remancipatio*; y en el caso del *usus* por el *trinoctium*.

Era necesario que el cónyuge que quisiese divorciarse manifestara su voluntad, por medio de una *servio receptitio*. En tiempos de Augusto y por medio de las leyes caducarías Julia y *Papia Poppaea*, se requería con carácter obligatorio que un cónyuge le comunicara esa voluntad al otro cónyuge verbalmente o por escrito delante de siete testigos, púberes y ciudadanos romanos.

Una vez que se había producido la disolución del vínculo había que determinar si los hijos que habían nacido de dicha unión eran legítimos, se prohibieron las donaciones.

El cónyuge que no había sido condenado a clausura, podía contraer enlace si se trataba del marido, pero si era la mujer debía esperar un año de luto salvo que antes tenga un hijo.

Si la culpable era la mujer perdía el derecho a las donaciones *propter nuptias*, y en la parte de la dote que se hubiese estipulado, si el culpable era el marido, adquiriría la mujer una porción de la *propter nuptias* igual a la estipulada en cuanto a la dote para el caso de que ella fuese culpable.

Los *filii* quedaban a cargo del cónyuge inocente; los gastos de educación debían ser costeados por el *pater* y si éste era indigente o estaba en extrema pobreza, debían ser costeados por la madre.

4) Nulidad del matrimonio

El matrimonio es nulo cuando no se cumplen con los requisitos exigidos por la ley, dado que al tratarse de un acto jurídico al faltar uno de ellos o al estar defectuoso traía aparejada como consecuencia la nulidad del acto jurídico, por ejemplo: por carecer del *connubium*, por falta del consentimiento de los contrayentes, por mencionar algunos.

En caso de bigamia o incesto se confiscaban los bienes que componían la dote o la donación.

Toda unión contraria a las leyes y a las buenas costumbres era denominada *stuprum*. Cuando la unión era con un hombre o mujer casados recibía el nombre de *adulterium*; y si se realizaba entre parientes o afines en grado prohibido se llamaba *incestum*.

Los hijos procedentes de un *stuprum* se llamaban *spurii* y se consideraban como vulgarmente concebidos (*vulgo concepti*): no existía a su favor ninguna presunción de paternidad, se encontraban unidos a la madre y a los parientes maternos por la cognación.

Existían demás penas pecuniarias y corporales; para el *stuprum* sin violencia, la confiscación de la mitad de los bienes o alguna pena corporal; para el *stuprum* con violencia, la muerte y lo mismo para la poligamia, el adulterio y el incesto.

VI. Concepto y Evolución histórica de la dote

A) La Dote. Concepto

Se designaba así al conjunto de bienes o cosas particulares de la mujer, su paterfamilias u otra persona que en su nombre aportaban por causa de matrimonio, con el fin de atender los gastos que demandaba al marido la vida matrimonial (*ad sustinenda onera matrimonii*).

La sociedad romana consideraba como un deshonor para la mujer concurrir indotada al matrimonio. Habría surgido como consecuencia del carácter del matrimonio cum manu, que al hacer que la mujer perdiera sus derechos hereditarios en su familia de origen justificaba la entrega a ella de bienes como anticipo de herencia. Con la vigencia del matrimonio sine manu, la dote implicó un aporte de la mujer para contribuir al mantenimiento de los *onera matrimonii*, no quedando la protección de la mujer una vez disueltas las nupcias.

La dote se configuró como una donación con causa onerosa, condición que surge no tanto del fin que perseguía, al servir al sostenimiento de las cargas matrimoniales, cuanto de la obligación del marido de restituir la dote en caso de disolución del matrimonio.

En la concepción romana originaria, la dote era propiedad exclusiva del marido y la mujer carecía de derecho sobre tales bienes. No obstante surge la idea de que aquella dote se debía tanto a la mujer, o que, hasta cierto punto le correspondía. La pertenencia especial de la dote a la mujer va apareciendo en la legislación romana en algunos aspectos que restringen la propiedad del marido. Así la *actio furti* es excluida para los objetos dotal es sustraídos por la misma, aplicándose para el caso una acción especial de “cosas movidas de sitio”. Por una *lex iuliade fundo dotali* de la época de Augusto, se prohibió al marido enajenar los fundos itálicos de la dote sin consentimiento de la mujer. El marido se hacía responsable por la pérdida de las cosas dotal es en la misma medida que a un poseedor de cosa ajena. Por fin se reconoció a la mujer el derecho de recuperar la dote al producirse la disolución del vínculo conyugal.

B) Clases, formas y constitución de la dote

El que constituía la dote fue en principio el *pater familias* de la mujer, cuando ésta era *sui iuris* le correspondía dotarse a sí misma.

Se llamaba *profecticia* si era constituida por el *pater familias*, y más tarde sobre el *pater* que no tenía la patria *potestas* sobre la mujer; dos *adventicia*: era la otorgada por la mujer misma, por su madre o por persona distinta del padre y; dos *recepticia*: la dote en la que el constituyente se reservaba el derecho de recuperar los bienes en caso de disolución del matrimonio.

C) Restitución de la dote

Disuelto el matrimonio, el marido tenía obligación de restituir la dote, en los primeros tiempos la misma operaba tácitamente en el matrimonio *cum manu*, porque siendo el fallecimiento del marido era el modo natural de extinguir el vínculo, tal hecho hacía heredera a la mujer.

Con el paso del tiempo se producen divorcios con frecuencia, entonces apareció la necesidad jurídica para hacer efectiva la restitución. A tal fin se introdujo en la práctica que el marido mediante estipulación, prometiera al constituyente la restitución de la dote en caso de divorcio, si el marido no cumplía se hacía exigible por la acción propia del contrato, la *actio ex stipulatu*. Se admitió también en el derecho post clásico, un pacto de restitución que las partes podían celebrar al hacer la transmisión inmediata de los bienes dotales. El constituyente podía exigir la restitución de la dote ejerciendo la *actio praescripti verbis*, que era la acción por la cual se demandaba el cumplimiento de los contratos innominados.

La falta de acuerdo sobre la restitución de la dote planteaba el problema de la imposibilidad de recuperar por parte de la mujer los bienes que se habían hecho propios del marido. Ante tal circunstancia se llegó a reconocer a la mujer, cuando el matrimonio se hubiera disuelto por divorcio, un derecho de restitución que se hacía efectivo

por medio de una acción pretoriana *ex fide bona*, la *actio rei uxoriae*. La acción correspondía a la mujer misma si era *sui iuris*, o el *pater* hubiese fallecido; si no se daba esa situación la ejercitaba el padre con el consentimiento de la hija.

El marido que tenía obligación de restituir la dote estaba autorizado, a retener cierta cuota de los bienes en caso de la existencia de hijos, retención que también podía hacer como sanción por el adulterio de la mujer, para castigar una conducta menos grave, por los gastos útiles que hubiera realizado y por las indebidas sustracciones que la mujer hubiera hecho de los bienes del marido. Con Justiniano el régimen de la dote experimenta profundas transformaciones tendientes a favorecer el interés de la mujer y que el marido solo tenía sobre los bienes dotales del usufructo. Se declaró restituible la dote en todos los casos de disolución del matrimonio.

D) Donaciones Nupciales

1) *Ante Nuptias y Propter Nuptias*

La donación hecha por el esposo, cuya validez dependía jurídicamente de la celebración y subsistencia del matrimonio, se denomina donación nupcial. Desconocida en el derecho clásico, aparece solo en el período posterior. La donación nupcial debía hacerse antes del matrimonio, al igual que la dote, estaba destinada a constituir una reserva a favor de la mujer y de los hijos.

En caso de muerte del marido o de divorcio sin culpa, la mujer retenía la donación. Si tenía hijos solo le correspondía un derecho de goce, ya que la propiedad pertenecía a los hijos. Si moría la mujer, la donación quedaba sometida a una regulación semejante, relativamente al marido y a los hijos.

2) Donaciones entre cónyuges: Es de suma importancia la que consagra la prohibición de las donaciones entre cónyuges del más generoso a desprenderse en beneficio del otro.

El principio, sin embargo, fue atenuándose y la jurisprudencia llegó a admitir la validez de las donaciones que no importaran un enriquecimiento para el donatario, como las que se hacían para procurar sustento a alguno de los cónyuges o motivadas en deberes sociales.

E) Capacidad jurídica y Capacidad de obrar

La edad para alcanzar la capacidad jurídica y de obrar, permitía la distinción entre púberes e impúberes. En la pubertad comienza a manifestarse la aptitud física para engendrar y para concebir, antes de esa edad la persona es incapaz de obrar.

La mujer en los pueblos indogermánicos siempre estuvo colocada en una situación de inferioridad a la del hombre. En Roma estaba excluida del ejercicio de las funciones públicas y por la naturaleza patriarcal de la familia se encontraba privada de todo poder en general, cuando ésta era *sui iuris*, o sea no se encontraba bajo el poder paterno (*patria potestas*), o bajo el poder de la *manus (maritalis)*, cualquiera fuera su edad se encontraba sometida a la tutela perpetua del sexo. Era incapaz de obrar, con incapacidad relativa; le estaba permitido realizar todos aquellos actos que pudieran producir beneficio patrimonial; para los demás necesitaría la *auctoritas tutoris*. La tutela perpetua del sexo fue limitada en el derecho clásico hasta que al final desapareció.

La posición de la mujer en la vida jurídica romana

Veremos algunas de los caracteres de la vida jurídica romana en cuanto al trato asignado a la mujer en su desempeño en la vida, su relación con su familia, con su marido, los *fili* y su trascendencia jurídica.

La mujer siempre se encontraba bajo la potestad de un varón libre, cuando nacía, la de su *pater* y si no tenía a éste, la de su marido o la de su tutor, era éste último caso denominado tutela perpetua de las mujeres.

Sin embargo no r aina situación de inflexión, por el *ius liberorum* de la *lex Iuliaet Papia Popaea* que las mujeres se liberan de ésta, exceptuando a las vestales, mujeres consagradas desde corta edad al culto de la diosa Vesta.

La Ley de las XII Tablas establecía que las mujeres tuvieran como tutores a sus agnados (parentesco proviene de la línea masculina).

En tiempos del bajo imperio se permitió a la madre y abuelas viudas que pudieran ser tutoras, una en defecto de las otras (en caso de no haber tutor testamentario) respecto de los hijos legítimos o naturales, siempre que:

- a) No se vuelvan a casar.
- b) renunciar a los beneficios del *Senatus Consultum Veleyanum*, que protegía a la mujer que se obligaba por terceros.

Les está permitido a las mujeres pedir a otro tutor en reemplazo del suyo que está ausente, pero hay una excepción y es el caso de la liberta que no puede pedir tutor para su patrono ausente.

Posición de la mujer en cuanto al concubinato

El concubinato se caracterizó por ser una unión con una mujer de baja condición social y sin *affectio maritalis*, sin honor *matrimonii* por lo que no ofrece obstáculo para que pueda ser confundido con el matrimonio legítimo.

En tiempos de Justiniano el concubinato sufre un cambio intrínseco que afecta a la misma esencia y es que el rango social no constituye ya un impedimento para el matrimonio y tampoco para el concubinato, desde que éste es posible con una mujer ingenua y honesta.

No se permitía el matrimonio entre la liberta y su patrono, sobre todo si ésta lo hubiera abandonado contra su voluntad, pero tanto en uno como en otro caso no se le permitía contraer *iustiae nuptiae*, sino mantener el vínculo de concubina, en igual situación quedaba la mujer adúltera, a quién se podía tener como concubina y no como mujer legítima.

La mujer que en estas circunstancias hubiera caído en locura es obligación del patrono no abandonarla.

El adulterio y el concubinato con la misma mujer es incompatible porque al ser el segundo una situación de hecho no es acorde al primero que es una creación de la ley y si bien había incompatibilidades para contraer matrimonio entre quién desempeñase un cargo en la provincia y una mujer de esa jurisdicción, la misma no subsistía si se trataba del concubinato.

Actos negociales de las mujeres

Debido a sus limitaciones en la capacidad negocial las mujeres tuvieron ciertos permisos en determinados casos, por ejemplo:

- El senadoconsulto Velejano, prohibió que las mujeres salieran de garantes a terceros. El sentido de ésta prohibición radicaba en que no hubiese conflictos familiares de origen patrimonial. Sin embargo le daba a la mujer una *actio* contra el deudor al cuál le había salido de garante, por considerarse que la mujer había sido engañada causa del perjuicio por el cual reclamaba.
- en tiempos de Augusto, después de Claudio se prohibió por edictos que las mujeres salieran de garantes de sus maridos, luego se dictó un senadoconsulto por el cual se les extendió protección, en lo que respecta a las fianzas y las daciones en mutuo a favor de otros, por los que éstas fueron garantes, no se da acción en contra de las mismas, para que no queden equiparadas a los hombres, considerándose éstas cuestiones más de hombres que propio de las mujeres.
- Los emperadores Antonino Pío y Severo por rescripto establecieron que se daba protección a las engañadas y no a las engañadoras.
- Se estableció que si la mujer era defensora judicial de cualquier persona, podía ser garante, al asumir una obligación ajena puede por éste motivo sufrir una condena, por lo tanto no se permite que la mujer pueda defender a su marido, hijo o padre.

Tutela

Cuando se hizo referencia a la persona vimos que quién reunía los tres status (hombre libre, ciudadano romano y *pater familia*) tenía plena capacidad jurídica, pero el resto de las personas libres que se encontraban bajo la *potestas* de éste *pater* no gozaban la mencionada capacidad jurídica plena: ocurría con los *filii*: estaban bajo el poder del *pater* no tenían capacidad jurídica hasta que no fueran cabeza de familia, la *uxor*: que por estar casada con el *pater* no tenía capacidad jurídica y si no estaba casada siempre estaba bajo el poder de algún varón: su *pater*, o en el caso de que no tuviera *pater* o marido quedaba bajo la tutela perpetua, aspecto que se tratará a posteriori, pero dentro de éste capítulo. A veces podía ocurrir que un *pater* falleciera y dejará a sus *filii* que si bien adquirirían plena capacidad jurídica y eran impúberes no eran capaces de ejercer por sí mismos sus derechos, o cualquier clase de acto jurídico que se propusieran, en ésta situación se encontraban aquéllos que no habían cumplido aún los catorce años; y las mujeres *sui iuris* de cualquier edad. En razón de su incapacidad de obrar, estaban sometidos al poder de un tutor, pero la tutela por razón del sexo perdió ya en el período clásico su antiguo rigor.

Origen de la palabra Tutor

Proviene de la voz latina *tueri*, que significa proteger, defender tenía sobre los impúberes y las mujeres un poder de protección similar, en cierto modo al reconocido al paterfamilias, atenuado por su finalidad tuitiva y de salvaguarda de los intereses patrimoniales respecto del incapaz o pupilo. Pero lo que hay que tener en claro es que ésta era en defensa de la persona y no del negocio/s en particular o no porque en la tutela lo que primaba era la persona.

La tutela correspondía a supuestos en que había una causa general y permanente de incapacidad, como la edad y el sexo.

La función del tutor era meramente civil; y también viril, por lo cual estaba vedada a las mujeres. Solo en la época cristiana, la legislación admitió que las mujeres, especialmente las que eran madres fueran tutoras.

La tutela era gratuita, no se cobraba remuneración por ejercer el cargo, pero el magistrado podía fijarle al tutor un honorario proporcional a las posibilidades del incapaz.

Definición

Servio la definió como fuerza y poder dada y permitida por el derecho civil de dar a quien por causa de la edad o del sexo no se podían defender a sí mismos.

Clases de Tutelas

a) Testamentaria

La designación de tutor por testamento era hecha por el paterfamilias y la misma recaía en otro *pater*, también en el hijo de familia en éste caso no era necesario que el magistrado investigara quien era el designado y su solvencia, pero sí debía hacerlo cuando la designación de tutor era hecha en el testamento de la mater.

Aquel que era nombrado si se lo hacía en un testamento inválido posteriormente era confirmado por el magistrado.

Si bien el esclavo no contaba con capacidad jurídica para ser tutor, podía serlo si el *pater* lo instituía su heredero, con lo que tácitamente era manumitido y luego podía ejercer dicha función, sin embargo esta cuestión no era aplicable a los peregrinos y a los *dedicticios*. Operaba también cuando el esclavo era designado por error creyéndoselo libre.

Al tutor testamentario le era permitido realizar la *Abdicatio Tutelae* para liberarse de ésta, se realizaba a través de un acto solemne en presencia de testigos, realizaba una *in iure cessio*, por la cual transmitía el ejercicio de la tutela a un extraño, pero si éste moría o sufría una *capitis deminutio* se reintegraba *ipso iure* al cedente.

Si se nombraba tutor a un *furiosus* o menor de veinticinco años había que esperar que el primero recobrase la razón y el segundo llegara a la mayoría de edad.

b) Legítima

Llamada así porque se interpretó que Ley de las XII tablas establecía quien era tutor, a falta de tutor designado por testamento; el ejercicio correspondía a los agnados más próximos del incapaz (hermanos, hijos de los hermanos, etc), si eran varios del mismo grado era ejercida conjuntamente, si eran impúberes había que esperar a que llegaran a la pubertad. En el derecho Justiniano se incluyen a los cognados.

c) Dativa

El Pretor junto con los tribunos de la plebe designaban un tutor para el incapaz que no lo tuviese, a partir de año 186 a.C. con la *Lex Atilia* que la crea. En tiempos del Emperador Marco Aurelio se le dio ésta facultad al Cónsul; en tiempos de Claudio se creó el cargo de *Praetor Tutoris*, aquél que se negara si no existía una causa justificada podía ser obligado, no hay que olvidar que ejercer la tutela era un honor, salvo que se den las causales de excusación.

d) Tutela Legítima del *Patronus*

Después de la tercera *mancipatio* el *filius* era manumitido de la *potestas* de su *pater*, para ya no volver bajo ésta como había ocurrido las dos veces anteriores. En éste caso quedaba bajo la tutela Legítima del *Patronus*, si éste moría quedaban como tutores legítimos sus agnados y sus hijos también heredaban el derecho de patronato. En ella se ve la relación entre tutela y *hereditas* ya que la ley de las XII Tablas establece como sucesores ab intestato del liberto al *patronus* y a los hijos de éste, por lo tanto éstos últimos podían ejercer la tutela.

e) Tutela fiduciaria

Denominada de ésta manera porque el tercero fiduciario es el que contribuye a la emancipación del *filius* y posterior manumisión de la *potestas* de su *pater*, la tutela ejercida por éste se transmitía hereditariamente a sus hijos. En la época de Justiniano eran tutores fiduciarios los hijos del *pater* manumisor, ejerciendo por lo tanto la tutela sobre sus hermanos/as.

f) Tutela de las Mujeres

Las mujeres *sui iuris* se encontraban sometidas a la tutela común *impuberum*, si eran impúberes; y a la especial y perpetua tutela *mulierum*, cuando hubieren llegado a los doce años y alcanzado por ende la pubertad. La institución se prolongó hasta el derecho clásico, que mantuvo el concepto de que las mujeres carecían de capacidad de negociar, pero con la progresiva independencia de la mujer fue disminuyendo la importancia de éste género de tutela a la par que se protegieron todos sus efectos. Ello hizo que en el derecho post clásico subsistieran débiles vestigios de la tutela *mulierum*, hasta que al final del período acaba por desaparecer.

Las funciones del tutor, debido a que la mujer tenía una incapacidad relativa de obrar, se reducían a la interposición de la *auctoritas* para dar validez a determinados negocios jurídicos de trascendencia patrimonial, como enajenarla *res Mancipi*, manumitir esclavos, obligarse, hacer *acceptilatio* de sus créditos, designar herederos por testamento y constituir dote.

El ocaso de ésta figura de tutela comienza al imponerse la costumbre de que, tanto el padre como eventualmente el marido cum manu, al nombrar tutor por testamento dejarán a las mujeres el derecho de designar ellas mismas el que quisieran. En la república tardía se ideó otro medio evitar la tutela, cuando la pupila no está autorizada por testamento para elegir tutor; la mujer se sometía mediante la *coemptio* a una persona de su confianza, quien la manumitía inmediatamente pasando a ser su patrono, con lo cual se convertía en tutor legítimo, con la denominación de tutor *fiduciarus*, un a potestas de ésta clase sobre la mujer también responde a la protección de intereses patrimoniales a los efectos de evitar que los bienes de la ésta pudieran pasar a otra familia.

Luego con el *ius liberorum* que se la daba a las ingenuas y a las libertas con tres o cuatro hijos, éste derecho desaparece completamente con HONORIUS y THEODOSIUS, quiénes en año 410 d.C. concedieron el *ius liberorum* a todas las mujeres del imperio, aunque parece no tener mucha explicación porque la tutela *mulierum* se exceptuó hasta ese momento.

A favor de la *uxor in manu* se ha admitido la *optio tutoris*, o sea que se le permite elegir el tutor que prefiera o el de su confianza.

Y la fórmula que se redactaba era la siguiente, por ejemplo: “Doy a mi mujer X la opción de tutor”.

Al principio la tutela de las mujeres era testamentaria, legítima según sea establecida por testamento o encargada a los agnados, a los gentiles o al manumisor.

Como tutor legítimo puede actuar un impúber lo que parece contradictorio con la institución.

Como sui iuris a la mujer, se le permiten determinados actos patrimoniales, pero para que fueran plenamente válidos debía contar con la *auctoritas* de su tutor, por ejemplo para realizar una in iure cessio, el usufructo, las manumisiones solemnes, etc. Pero cuando decae la *manus* y la mujer con cuenta con la *auctoritas* para la celebración del negocio igualmente éste es válido.

En cuanto a la tutela de sus agnados se le permite a la mujer que pueda someterse a la *manus* de alguno de su confianza a través de la cometió, con el pacto de que aquél debe emanciparla y constituirse en su tutor fiduciario.

Los tutores designados nominalmente en el testamento son llamados “dativos”, y aquellos que resulten elegidos en la opción “optivos”.

El esclavo menor de treinta años puede llegar a ser ciudadano romano si su dominus, que no fuera solvente, lo manumite por testamento y lo instituye heredero (sin excluir a ningún otro heredero); esto también está dispuesto por la Lex Aelia Sentia.

Causales de excusación para ejercer la Tutela

El término excusación se refiere a que nadie puede ser obligado a aceptar el cargo de tutor si se encontraba dentro de las causales que se lo impedían, para ello debía manifestar la existencia de la misma en el término de cincuenta días, ante el magistrado.

Como se dijo anteriormente el ejercicio de la tutela era un honor, por lo tanto una carga y no podía ser rechazado sin que existiera una causa que lo justifique, y éstas podían ser:

- estar ejerciendo otras tutelas
- tener residencia alejada a la del pupilo
- tener muchos hijos
- enfermedad
- vejez
- estar formando parte del ejército

Obligaciones del tutor antes, durante y después de la tutela:

a) Responsabilidades antes de empezar a ejercer la tutela

Quien va a asumir el cargo de tutor deberá hacer un inventario de los bienes del que va a ser su pupilo, ello deberá ser verificado por el magistrado quién controlará que se haya cumplido, en caso contrario ante cualquier reclamo por mala administración se tendrá por cierta

la palabra del pupilo, quizá como una forma de castigar a quien ha actuado negligentemente sin perjuicio del ejercicio de las acciones pertinentes que luego se verán. La finalidad del inventario es devolver los bienes que se han recibido para administrar o sus mejoras.

El que iba a ser tutor no podía tener un patrimonio inferior al del que iba a ser su pupilo, ello es lógico para evitar que, quien se fuera hacer cargo de la administración patrimonial no se enriqueciera a costa del perjuicio de su pupilo, se evitaban los conflictos de intereses; sin embargo el que asumía dicha responsabilidad debía dar caución suficiente de que iba a realizar una buena labor.

Si el que iba a ser pupilo no hacía uso de la palabra el que iba a ser tutor celebraba una *satisfatio* (variante contractual verbal de la *stipulatio*) con un esclavo del primero por la cual se comprometía a dar caución suficiente a la vez de que iba a realizar una buena administración patrimonial. Era de carácter obligatorio con respecto a los tutores dativos.

A veces ocurría que quienes iba a participar de éste vínculo en algún momento se habían constituido recíprocamente como deudor y acreedor, de modo que cuando se comenzara a ejercer la tutela dicha relación crediticia quedaba suspendida para evitar conflicto de intereses.

b) Responsabilidades durante el ejercicio de la tutela

El tutor actuaba de dos maneras según la edad del pupilo:

- 1) Con la *Gestio* en el caso de los impúberes *infantiae proximi* (de 0 a 7 años de edad) actuando en los actos *negociales* a nombre propio pero a cuenta del pupilo, actúa como gestor del pupilo.
- 2) Con la *Auctoritas*: En relación a los impúberes *pubertati proximi* cuyas edades oscilaban de los 7 a los 14 años aproximadamente, los actos jurídicos son realizados por el incapaz pero con el consentimiento o respaldo del tutor.

El tutor podía ser titular de derechos reales, de obligaciones (ya sea como deudor o acreedor), y lo transfería al patrimonio del pupilo, podía entregar en prenda bienes del pupilo pero su actuación era limitada no podía realizar determinados actos como aceptar una herencia, realizar una *acceptilatio*.

La *auctoritas* es un acto personalísimo, que se tiene que realizar en el mismo acto para el que presta su consentimiento completando la capacidad del pupilo, significa que para llevar a cabo un acto jurídico no puede enviar a un tercero en su representación.

c) Responsabilidades una vez finalizado el ejercicio de la tutela

- El tutor debía rendir cuentas de su labor en base al inventario que se había hecho al comienzo del ejercicio de la tutela, debiendo por tanto, restituir los bienes del pupilo.
- Ante eventuales conflictos emergían las siguientes acciones.

Acciones que se podían ejercer

a) *Actio Tutelae Directa*

Ejercida por el pupilo en contra de su tutor con el fin de reclamar de él y de sus herederos una indemnización como consecuencia de los daños sufridos por la mala administración realizada.

b) *Actio Tutelae contraria*

Era ejercida por el tutor en contra de su pupilo al que le reclamaba el reintegro de los gastos realizados para la conservación de los bienes del patrimonio.

c) *Accusatio Suspecti Tutoris*

Si durante el ejercicio de la tutela el tutor es sospechoso de estar realizando actos fraudulentos en perjuicio de su pupilo se lo removía y se le designaba otro. El conocimiento de la causa del tutor sospechoso le compete a quién tiene jurisdicción según sea el domicilio del pupilo, la jurisdicción la tenían los Legados de los Procónsules y era extensiva a la curatela.

d) *Actio de Rationibus Distrahendis*

El tutor le paga a su pupilo una multa a título de daños y perjuicios por la mala administración de su patrimonio, equivalente al valor de los bienes defraudados.

e) *Acción Subsidiaria*

En beneficio del pupilo y en contra del magistrado a quien se demandaba ya que no había verificado la realización del inventario por parte de quien iba a ser tutor, también prosperaba cuando no verificaba la caución dada por el último.

f) *Privilegium Exigendii*

Una vez que finalizaba el vínculo creado por la tutela, si el pupilo era deudor o acreedor de su ex tutor los créditos renacían a la vida jurídica y se exigían, el ex pupilo tenía preferencia a los acreedores quirografarios.

g) *Actio Utilis Tutelae*: Se daba en contra del tutor dativo inoperante.

Fin del ejercicio de la Tutela

- a) cuando el pupilo muere o sufre una *capitis deminutio*;
- b) cuando éstos llegan a la pubertad.
- c) si se hizo por testamento y se cumplió el plazo o condición fijado en él.
- d) cuando el tutor es removido de su cargo.
- e) cuando se admite la excusación de éste.
- f) cuando el tutor es designado bajo condición una vez que se haya cumplido ésta.
- g) Si el tutor cae en manos del enemigo, cesa en el ejercicio hasta que vuelva a Roma como consecuencia de la aplicación del *ius postliminium*.
- h) *capitis deminutio* máxima o media del tutor.

La curatela

1) Concepto

Era una potestad que se ejercía sobre determinadas personas, y la finalidad consiste en la administración de su patrimonio.

2) Clases: Ellas eran las siguientes:

- a) los menores de veinticinco años
- b) los pródigos
- c) los *furiosi*

a) Los Menores de Veinticinco Años

Es la situación en la que se encontraban aquellos que si bien eran púberes, estaban comprendidos entre las edades de catorce (los varones) o doce (las mujeres) no eran suficientemente aptos para cuidar de sus intereses.

Esto último se determinó con el paso del tiempo ya que si bien tenían plena capacidad jurídica, por ser tan jóvenes no tenían la experiencia necesaria para desenvolverse en la realización de los negocios jurídicos y resultaban perjudicados patrimonialmente en ellos.

Como no había normas jurídicas que solucionaran ésta cuestión apareció la *Lex Plaetoria*, y entre otras penas acarrea la tacha de infamia para quien en la realización de un negocio hubiese perjudicado a un menor de veinticinco años, pero se observó que no había solución para el perjuicio patrimonial; entonces el pretor concedió la *in integrum restitutio* declarando la nulidad de lo actuado y la restitución de lo recibido en ocasión del negocio celebrado, dadas éstas circunstancias, los terceros veían que si celebraban un negocio jurídico con un púber menor de veinticinco años no tenían garantías de que el negocio no se declarara nulo, por lo tanto no se arriesgaban, entonces se decide que éstos menores debían contar con una protección también eficaz para esos terceros que fue la designación de curadores, pero era de carácter voluntario pedir al magistrado un curador.

La curatela de ésta clase podía ser legítima o dativa, no podía ser testamentaria, si esto último ocurría era confirmado por el magistrado.

La protección podía ser para un solo negocio o para todos, nadie podía ser obligado a recibir *curator*, solo era viable ésta posibilidad para el incapaz que tuviera que litigar y no tiene quien vele por sus intereses.

b) Los Pródigos

Es el sujeto que dilapidaba los bienes recibidos por sucesión de la línea paterna. Por tal motivo ésta actitud perjudicial no solo alcanzaba al prodigo sino a su familia por tal motivo el magistrado lo declaraba incapaz y se le asignaba como *curator* a sus agnados o en su defecto a los gentiles.

Guarda similitudes en lo que se refiere a las normas que rigen al *furiosus*, por lo tanto podía ser temporal.

c) El Furiosus

Se hacía la diferencia entre aquellos sujetos que tenían una disminución en su capacidad mental era el *mente capti*; del que estaba completamente privado de su razón el *furiosus* o demente.

En el último caso era necesaria la designación de un *curator* por la gravedad de la cuestión, con el fin de que velara por su persona y administrara su patrimonio.

La designación del *curator* no se podía hacer por testamento, ya sea que la designación provenga de la *mater* o del *pater*, para ello era necesaria la confirmación por parte del magistrado.

Aunque tuviera más de veinticinco años, de acuerdo a lo establecido por la Ley de las Doce Tablas, la designación recaía sobre sus agnados.

Se establecía que el Presidente de Provincia debía disponer el encierro de un *furiosus* en el caso de que su familia no lo pudiese contener, como también por rescripto de Pío se había dispuesto que, si

un *furiosus* había cometido el delito de *homicidium* había que hacer un examen exhaustivo para determinar si realmente era loco o fingía, porque si no estaba *furiosus* debía ser encerrado para cumplir una pena, pero en cambio sí lo era, no se le aplicaba una pena pero debía ser encerrado, porque bastante castigo es su furia.

El encierro del *furiosus* tal como se señala por rescripto lo importante que es para su castigo como para su custodia y seguridad de los parientes.

Si recuperaba la lucidez esta debía ser por un lapso prolongado y le debía constar al resto de la comunidad con el fin de que no dejara lugar a dudas, ya que los actos jurídicos que el sujeto celebrase eran válidos, aún cuando posteriormente se convirtiera nuevamente en un *furiosus*.

Si se trataba de un caso de homicidio y se presumía que el autor era furioso al momento del hecho, había que esperar los períodos de lucidez para hacer las averiguaciones pertinentes, indagándose también a quienes lo cuidaban en esa época, y si hubo negligencia se accionara en contra de ellos, ya que a los furiosos se les ponen guardas para que no se dañen a sí mismos o a terceros.

Las modalidades descriptas se hacían extensivas a los sordos y a los mudos. Para éstos últimos se designaba un curador honorario.

3) Otros casos en los que se reciben curadores

Había otras situaciones además de las descriptas en las cuales se designaba *curator*: por ejemplo un tutor designado que no sea idóneo en la administración patrimonial, pero no intencionalmente se le designa a la vez un *curator*, o en el caso en que los tutores se excusan por un tiempo. También por problemas graves de salud del tutor, o por alguna imposibilidad que no le permita cumplir esa función se hacía una designación por el pretor o presidente de provincia.

4) Actuación de los curadores

A los fines de garantizar una correcta administración patrimonial de sus pupilos los curadores debían hacer una *satisfactio* (contrato verbal

derivado de la *stipulatio*), por el cual daban cauciones o garantías comprometiéndose a desempeñar su cargo con fidelidad de buena administración y cuidado de las personas de sus pupilos. Quedaban exceptuados de ésta regla los curadores testamentarios o aquellos que han sido designados luego de una investigación sumaria dado que los mismos han sido justamente elegidos por su idoneidad para el cargos que ocupan.

5) Acciones emergentes del ejercicio de la tutela y de la curatela

h) Actio negotiorum gestorum Directa

Ejercida por el pupilo en contra de su tutor o curador con el fin de reclamar de él y de sus herederos una indemnización como consecuencia de los daños sufridos por la mala administración realizada.

i) Actio negotiorum gestorum contraria

Era ejercida por el tutor o curador, en su caso, en contra de su pupilo al que le reclamaba el reintegro de los gastos realizados para la conservación de los bienes del patrimonio.

j) Accusatio Suspecti Tutoris vel curatoris

Si durante el ejercicio de la tutela / curatela el tutor si curador es sospechoso de estar realizando actos fraudulentos en perjuicio de su pupilo se lo removía y se le designaba otro. Cualquier tutor o curador puede ser removido por ser acusado de sospechoso, cualquiera puede acusar, incluso las mujeres (generalmente las que guardan una relación de parentesco con los pupilos). Los impúberes no pueden acusar pero los púberes sí, pueden hacerlo con respecto a sus curadores. Se diferencia también el acusado que ha actuado con mala intención o sea, quiso causar daño, de aquél que ha obrado negligentemente, en el primer caso el mismo es alcanzado con la tacha de infamia.

Entre las causas podemos mencionar algunas: la negativa a prestar alimentos al pupilo, por pobreza del curador o tutor aunque sea fiel y diligente, el que alega falsamente pobreza del pupilo y por ese motivo no le brinda alimento.

k) Actio de Rationibus Distrahendis

El tutor o curador le paga a su pupilo una multa a título de daños y perjuicios por la mala administración de su patrimonio, equivalente al valor de los bienes defraudados.

l) Acción Subsidiaria

En beneficio del pupilo y en contra del magistrado a quien se demandaba ya que no había verificado la realización del inventario por parte de quien iba a ser tutor o curador, también prosperaba cuando no verificaba la caución dada por el último. Se denominaba de ésta manera porque era “subsidiaria” a la acción que ejercía contra quienes habían realizado *satisfatio*.

m) Privilegium Exigendii

Una vez que finalizaba el vínculo creado por la tutela o curatela, si el pupilo era deudor o acreedor de su ex tutor/ ex curador los créditos renacían a la vida jurídica y se exigían, el ex pupilo tenía preferencia a los acreedores quirografarios.

n) Actio Utilis Tutelae et curatoris: Se daba en contra del tutor/ curador dativo inoperante.

6) Causas por la cuales se podía excusar el curador

El término excusación se refiere, al igual que en la tutela a que nadie puede ser obligado a aceptar el cargo de curador si se encontraba dentro de las causales que se lo impedían, para ello debía manifestar la existencia de la misma en el término de cincuenta días, ante el magistrado.

Como se dijo anteriormente el ejercicio de la tutela o de la curatela era un honor, por lo tanto una carga pública y no podía ser rechazado sin que existiera una causa que lo justifique, y éstas podían ser:

- estar ejerciendo otras tutelas o curatelas: tres por lo menos.
- tener residencia alejada a la del pupilo
- tener muchos hijos bajo su *potestas* o emancipados, el que tiene en Roma tres hijos vivos, en Italia cuatro. No se incluyen a los hijos adoptivos, ni a los fallecidos salvo que hayan

- muerto en el campo de batalla defendiendo a Roma.
- por enfermedad
 - por vejez
 - estar formando parte del ejército o quienes participaban de las guerras, mientras tanto se nombra un tutor o curador en su lugar.
 - quien administra el fisco, mientras dure en ese cargo
 - en el caso de que haya un litigio entre tutor y curador y estén en juego todo el patrimonio o una herencia.
 - por pobreza.
 - quién no sabe escribir
 - los gramáticos, los retóricos y los médicos.

FRANJA
MORADA

I. ¿Qué es la Sucesión?

Suceder a una persona que ha muerto es continuarlo en sus derechos y obligaciones además de su materialidad, o elementos corpóreos (bienes).

Cuando se estudiaron los aspectos centrales de la persona recordemos que la muerte extingue a la persona y al homo, como se ha visto en la unidad temática de persona. La extinción física tiene repercusiones jurídicas con respecto a la nueva titularidad de los bienes que hay que suceder y ciertos derechos que tenía el de cuius se extinguen por el carácter personalísimo que tenían, mientras que aquellos que son de carácter patrimonial, mantienen su vigencia en cabeza de, el /los here/s . Se produce así la Successio Mortis Causa.

Este instituto está íntimamente relacionado al derecho de familia, los derechos patrimoniales y por supuesto a la historia misma del Derecho Romano

Desde el punto de vista jurídico hay que tener en cuenta que, para que se produzca el fenómeno de la transmisión del difunto al heredero, es necesario referirse al patrimonio como una universalidad jurídica; porque de esa manera se ha comenzado el estudio de los derechos patrimoniales. El patrimonio, no solo es un conjunto de cosa corpóreas sino también que la misma está compuesta de derechos y obligaciones que recaerán en la cabeza del here que acepta la herencia, o del heredero que la recibe automática, como lo explicaré más adelante, por ese motivo el patrimonio se acepta en bloque o no se acepta, es decir, se acepta con las cosas materiales y las cargas; pero, si se diera el caso de quien no quiera recibirlo pasará a acrecer la porción de otro here o será una hereditas iacens. Así quien se convierta en heredero sustituirá a un sujeto en lo referente al patrimonio, lo sustituye o entra en su lugar otro, con lo cual permanecen inalterables los derechos que tenían por titular al sujeto original, el único cambio que se produce es el de los sujetos que intervienen, o sea, el de *cujus* y el heredero.

Dicho de otra forma, recordando la definición de patrimonio es sabido que no solo constituyen la *hereditas* las materialidades sino también las inmaterialidades, por ejemplo si el de *cuius* era deudor de Ticio, su *here* Juliano será a partir de la aceptación de la herencia deudor de Ticio.

De la herencia, el heredero recibirá no solo los bienes que la componen sino también las cargas, es inadmisibles que se acepten ambos por separado, no se puede aceptar o repudiar la herencia por partes.

II. Clases de sucesiones

También hay que tener en cuenta que, cuando se utiliza el término Sucesión no siempre hay que asociarlo con la causal de muerte y sus consecuencias jurídicas, ya que la *succesio* no solo era *mortis causa*, sino también podía ser *inter vivos*, como lo era el caso de la *Bonorum Venditio* explicado en las formas de ejecución patrimonial en tiempos del procedimiento formulario.

La Sucesión por causa de muerte era, por tanto a título universal, era la *hereditas*.

La *successio* inter vivos era a título universal: *Bonorum Venditio* o a título particular: la compraventa.

La Institución del legado no es una *successio* a título particular porque, el legatario recibe un bien o conjunto de bienes y no continua a la persona del causante en otras cuestiones jurídicas o personales relacionadas a ellos. Además entre ellos hay un intermediario que es el heredero; mientras que en la *successio* por causa de muerte ente el heredero y el de *cujus* no intervienen intermediarios.

III. ¿Qué es la *hereditas*?

Era la res universal a la que se hacía referencia anteriormente, entendida como un conjunto de derechos y obligaciones que integraban el patrimonio del causante. Quién era llamado a recibirlo era el *heres*, el heredero según el derecho civil, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de las XII Tablas y más tarde por los *senadoconsultos* y de las constituciones imperiales. Se trataba de un sucesor o continuador de toda la herencia, un sucesor universal (*in universum ius*), no particular porque no existía. Era continuador de la personalidad jurídica del de *cuius* o causante.

a) Por acto entre vivos (*successio inter vivos*)

En la sucesión entre vivos, como en la *mortis causa*, la sustitución o cambio de un sujeto por otro podía verificarse en la totalidad o conjunto de sus derechos y obligaciones y también las materialidades aquí estamos ante la sucesión a título universal (*per universitatem, successio in universum ius*); en el caso que se transmita un bien o conjunto de bienes en particular, no se transmiten los derechos y obligaciones; estamos ante la transmisión a sucesión a título particular o singular (*in singulas res*).

Entre los casos de sucesión universal *inter vivos* pueden recordarse el de la adrogación, el de la legitimación y el del matrimonio *cum*

manu de la mujer *sui iuris*, en los que personas libres de potestad pasaban a la condición de *alieni iuris*, colocándose bajo la *potestas* o *manus* de un *paterfamilias*. La sucesión particular entre vivos se presenta en la compraventa, en la cesión de créditos, la *bonorum venditio*, etc.

b) Por causa de muerte (*successio mortis causa*)

Significa el cambio de titular en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles de una persona a partir de su fallecimiento.

Las sucesiones universales por causa de muerte reconocidas por el derecho romano fueron la herencia (*hereditas*), que tuvo su origen en el derecho civil, y la posesión de bienes (*bonorum possessio*), que tuvo regulación en el derecho pretoriano u honorario.

Se debe aclarar que el legado, o disposición de bienes contenida en un testamento como una cláusula que importaba una carga para que el *here* cumpliera, no constituyó la sucesión particular *mortis causa* dado que al transferirse un bien o conjunto de bienes en particular no se transferían las cargas que emergían de él.

La sucesión por causa de muerte, en la que el fallecimiento de una persona es el hecho fundamental que le da origen, como la causa provoca el efecto (*viventis nulla hereditas*), es un acto jurídico, que nace por voluntad del testador o por imperio de la ley.

La sucesión por causa de muerte es uno de los modos de adquisición de derechos patrimoniales. Las normas no lo incluían como parte del *ius privatum*, aparecía como uno de los modos derivados de adquirir la propiedad.

IV. Las formas de transmisión

La transmisión por causa de muerte podía ser:

1) Testamentaria

Etimológicamente proviene de *testatio mentis*, o testimonio de la voluntad. Es la declaración de última voluntad de una persona realizada en vida que repercutirá jurídicamente para después de su muer-

te siempre que cuente con capacidad jurídica no solo al momento de testar sino también al de su muerte. Pero esto no es suficiente ya que será necesaria la institución de heredero, caso contrario no será un testamento sino una mera manifestación de última voluntad, para ello será suficiente con dos palabras; “LUCIUS HERES” (Lucius herédame).

Es testamentaria cuando el difunto ha designado con anticipación las personas llamadas a sucederle, es un acto voluntario y conforme al derecho, y es unívoco. Además de instituir heredero podía establecer otras cláusulas: designación de tutores, manumisiones, legados, donaciones, por mencionar algunas. No había límites para la designación de herederos.

2) Intestada o ab intestato

Cuando a la falta de testamento o en caso de su invalidez, la ley designaba los herederos, fundándose en la organización de la familia –como ocurrió en el derecho primitivo- o en los presuntos afectos del causante.

Aunque de contenido esencialmente patrimonial, la herencia podía integrarse con algunos elementos extra patrimoniales accesorios; como el culto familiar de los antepasados (*sacra privata*), el derecho de sepulcro (*ius sepulchri*) y el derecho de patronato sobre los libertos (*iura patronatus*).

Si bien la herencia podía contener elementos extra patrimoniales, no eran transmisibles hereditariamente algunos derechos de naturaleza patrimonial. Las servidumbres personales de *usufructo*, *uso* y *habitación*; ciertos derechos de crédito cuyo objeto consistía en prestaciones personales, como ocurría en el mandato, la sociedad, la locación de servicios y de obra y algunas acciones penales, que se extinguían con la muerte del autor de la sucesión.

V. Requisitos para que opere la sucesión testamentaria

Para adquirir la calidad de heredero era necesaria la concurrencia de ciertos presupuestos o condiciones:

a) Condición de carácter general: la muerte de la persona.

Era un presupuesto importante de la sucesión hereditaria el fallecimiento del individuo era condición legal para que produjera sus efectos (*hereditas viventis non datur*).

b) Condiciones particulares

1) Capacidad del difunto para tener heredero.

a) El causante tenía que ser capaz (ser libre, ciudadano y sui iuris).

b) el varón contar con catorce años y la mujer con doce, además de ello era necesario que esté en su sano juicio independientemente de su salud física, ya que si había perdido algún miembro podía testar.

c) Eran incapaces, para tener herederos, los esclavos, peregrinos, los sordos y los mudos.

d) También los *filiifamilias*, éstos últimos ni siquiera lo podían hacer con el consentimiento de su pater pero al morir estos últimos, aún después de establecidos los peculios castrense y cuasi castrense, dichos bienes revertían al *pater*, no *iure hereditatis*, sino *iure peculii*. Con Justiniano, al ampliar el peculio adventicio a todas las adquisiciones del *filius*, se reconoció a éste capacidad para tener sucesor.

e) Quién fue castigado con la interdicción del agua y del fuego vale el testamento hecho antes pero no el posterior

f) Tampoco pueden testar los deportados a una isla, ni los relegados que fueron expulsados de Italia o de alguna de sus provincias.

g) Ni quienes han sido condenados a muerte, a las fieras o a trabajar en las minas como consecuencia de haber perdido su libertad.

- h) Pueden testar los capturados por atracadores, ya que no han perdido la libertad.
 - i) También el encarcelado antes de ser condenado, y el condenado a pena que capital que hubiese apelado tal decisión, siempre y cuando hubiese testado y muerto antes de que se resolviera tal cuestión.
 - j) No pueden quienes dudan de su estado, ni el pródigo.
 - k) El cautivo en poder del enemigo, se aplicará según corresponda la *fictio Legis Corneliae* o el *Ius Postliminium*.
- c) Capacidad del heredero para suceder.

Se exigía también que el llamado a la sucesión fuera libre, ciudadano, y sui iuris. Los esclavos y los *fili* familias eran propiamente incapaces, salvo que se los instituyesen herederos por testamento, en cuyo caso adquirirían para la persona bajo cuya potestad se encontraban. A raíz de los bienes adventicios, el *filius* pudo heredar para sí, ya sea por testamento o por disposición de la ley.

VI. Clases de testamentos

a) El Testamento Oral

Quienes van a ser instituidos deberán ser nombrados de manera clara de modo que no quede lugar a dudas para quienes ofician de testigos, pero si terminado el acto se quiere hacer alguna modificación éste deberá hacerse de nuevo como si nunca se hubiese hecho.

Por el Derecho Civil había tres formas de testar:

b) El *Testamentum Calatis Comitiis*

Era uno de los más antiguos que se han conocido, se realizaba dos veces por año: el 24 de marzo y el 24 de mayo en presencia del Pontífice Máximo y el pueblo, que asentía el acto que se realizaba ante su presencia, usado en tiempos de paz, se llevaba a cabo en presencia del *populus* con el fin de que éste diera su aprobación debido a la importancia de testar ya que la designación de un heredero traería